

1501727-22.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501727-22.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501727-22.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337351/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 21899311 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2337351 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAILSON DA PAZ SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1501727-22.2021.8.26.0603 (Controle 2502/2021)

VISTOS.

NAILSON DA PAZ SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito,

denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 22h10, à Rua Wagih Rahal, 885, Jardim Perola, nesta cidade e Comarca de Birigui, guardava e mantinha em depósito no interior de sua residência, com o fim de tráfico, 862,4g (oitocentos e sessenta e dois gramas e quatro centigramas) de Cocaína, na forma de 01 tijolo; 1088,16g (mil e oitenta e gramas e dezesseis centigramas) de Maconha, fracionados em 02 tijolos; 328,39g (trezentos e vinte e oito gramas e trinta e nove centigramas) de Cocaína, fracionados em 248 invólucros plásticos; 159,05g (cento e cinquenta e nove gramas e 5 centigramas) de cocaína, acondicionados em 01 invólucro plástico e 12,74g (doze gramas e setenta e quatro centigramas de Maconha), em uma só porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 778 "ependorfs" vazios, R\$ 2.276,00 em espécie, 01 prato de vidro com resquícios de drogas, 01 pacote de "saquinhos para gelinho", 02 rolos de sacos plásticos, 02 balanças de precisão e 04 telefones celulares, conforme boletim de ocorrência de fls. 28/34, auto de exibição e apreensão de fls. 37/39, laudos de constatação prévia de fls. 54/58, laudos periciais fls. 140/154, fotografias de fls. 47/53 e comprovante de depósito de fls. 129.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 263), cuja peça foi juntada às fls. 265/267, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 24/05/2022 (fls. 333/337) e a citação do acusado à fl. 313.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 328/329).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 333/337).

A defesa, por sua vez, alegou, em preliminar, ilicitude da busca realizada pelos policiais na residência e a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, requer a condenação do réu, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o direito do réu recorrer em liberdade (fls. 341/354).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A matéria arguida pela defesa, quanto à busca domiciliar na casa do acusado sem mandado judicial, fica rejeitada e, conseqüentemente, afastada a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Pelo que se relatou, os policiais militares abordaram o acusado e Roger e localizaram uma porção de maconha, dois celulares e 2.276,00 em notas diversas, pertencentes ao acusado. Indagado, o acusado disse que guardava drogas em sua residência. No local, franqueada a entrada pelo acusado, foram localizados 01 tablete de maconha, 01 tablete de cocaína, 248 micro tubos, também com cocaína, outros 778 micro tubos vazios, 02 balanças digitais de precisão, 02 rolos de plástico filme, um prato contendo resquícios de entorpecentes e 01 celular.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de

represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar:

“De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formado disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Em função disso, sempre que houver fundada suspeita da ocorrência do referido ilícito penal, não será possível falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio ou específico, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Afirmar-se o contrário implicaria prestigiar a atividade criminosa, em detrimento do trabalho policial realizado por agentes

públicos regularmente investidos em suas funções, que ficariam inviabilizadas, com prejuízo irreparável para a sociedade. Imagine-se, por exemplo, que policiais estivessem realizando ronda rotineira, no exercício do policiamento preventivo e, ao passarem diante de uma residência qualquer, ouvissem gritos de socorro de uma mulher. A prevalecer o raciocínio segundo o qual o ingresso em residência só pode ocorrer quando houver segura conclusão acerca de crime em seu interior, mesmo diante da suspeitada ocorrência de violência doméstica, os agentes públicos estariam impossibilitados de intervir, e só poderiam ingressar na residência após a obtenção de ordem judicial, ou se a tanto autorizados pelo possível agressor, ou seja, quando o socorro à vítima já não seria mais útil. Tão absurda situação equivaleria à concessão de um passe livre para que residências servissem de palco para a prática dos mais diversos e graves delitos (homicídios, sequestros, lesões corporais, tráfico, estupro de vulneráveis, etc.), colocando a proteção às vítimas e da sociedade em patamar inferior aos direitos dos criminosos, e privilegiando a impunidade)... E nem se diga, por outro lado, que a diligência policial não foi devidamente documentada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se exigia documentação e registro audiovisual para o ingresso de policiais em residências (Habeas Corpus nº 598051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP, de que foi relator o Ministro Alexandre de Moraes, realizado no dia 02 de dezembro de 2021, ficando assentado que é “Incabível, portanto, na presente hipótese, em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias, para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”. Enfim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem é o caso de se determinar o desentranhamento de qualquer elemento probatório dos autos, já que todas as provas produzidas se afiguram válidas. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439, Comarca de Pereira Barreto, 11ª Câmara de Direito Criminal,

V.U., j. 03/02/22, rel. Des. XAVIER DE SOUZA).

No mérito, a ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o recibo de entrega de preso (fls. 02/03); o boletim de ocorrência (fls. 28/34); a nota de culpa (fl. 07); o depósito judicial (fl. 129); o relatório final (fls. 153/159); os laudos de constatação prévia (fls. 54/58); os laudos periciais (fls. 140/154); os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia e em juízo, o acusado confessou, dizendo que as drogas e os apetrechos, que estavam em sua residência, pertencia a outra pessoa e ele estava guardando a troco de R\$1.000,00 por semana. Disse que a maconha encontrada no veículo iria consumir com Roger, o qual estava junto no veículo, quando os policiais militares os abordaram. O dinheiro apreendido R\$1.200,00 pertencia à esposa e o restante era de seu trabalho. O veículo pertence à seu pai. Falou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência (fls. 06 e 328/329).

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, as testemunhas Marcos Vinicius Aragão de Almeida e Igor Ilan Argentato, policiais militares, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, relataram que abordaram um veículo, sendo apreendidos uma porção de maconha, dois celulares e R\$ 2.276,00 em dinheiro. Indagado, o acusado disse que em sua residência havia mias drogas. No local. O acusado autorizou a entrada e indicou onde armazenava as drogas. Foram apreendidos um tablete de maconha pesando em torno de 01 (um) quilo e 15 gramas, cerca de 860 (oitocentos e sessenta) gramas de pasta base para cocaína; 248 (duzentos e quarenta e oito) micro tubos com cocaína e outros 778 (setecentos e setenta e oito) vazios, duas balanças digitais de precisão, rolos de plástico filme, celular e um prato. O acusado informou que a droga pertencia à Diego Cassimiro e que ganhava R\$ 1000,00 (um mil reais) por semana para armazenar as drogas (fls. 02/03, 04 e 328/329).

Os policiais confirmaram que localizaram quantidade considerável de entorpecentes e apetrechos para embalar as drogas, e que o réu confessou que estava guardando os entorpecentes.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha Roger Yago Duarte, ouvida na fase policial, disse que, juntamente com o acusado, saíram para fumar maconha e foram abordados pelos policiais militares. Não sabia que o acusado tinha droga na casa dele e nunca soube que ele era traficante ou que guardava drogas para alguém (fl. 05).

A testemunha Diego Cassimiro, ouvido na fase extrajudicial, relatou que conhece o acusado, mas não tem amizade com ele. Não pediu para ele guardar drogas nem vender (fl. 136).

As testemunhas de defesa Reginaldo Matias da Silva e Elisandre Rodrigues da Silva, ouvidas em juízo, nada souberam esclarecer sobre os fatos, limitando-se em tecerem

comentários sobre o réu (fls. 328/329).

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consistem realmente em "maconha" e "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 140/152).

De outra parte, a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 862,40g de cocaína, 1081,16g de maconha, 328,39g de cocaína, 159,05g de cocaína e 12,74g de maconha; as circunstâncias da abordagem do réu (réu informou que estaria guardando drogas em sua residência); a apreensão da balança de precisão, plástico filme, dinheiro, celulares e epperdorfs vazios, e a confissão do réu em ambas as fases da persecução penal, estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foram apreendida duas balanças de precisão, epperdorfs vazios, prato com resquícios de cocaína e plástico filme juntamente com as drogas, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, estes apetrechos são utilizados para quantificar as porções que serão vendidas.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente guarde ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado guardar e manter em depósito os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita, e não arrolou sua esposa, para confirmar que parte do dinheiro lhe pertencia, razão pela qual, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava e mantinha em depósito 862,4g (oitocentos e sessenta e dois gramas e quatro centigramas) de Cocaína; 1088,16g (mil e oitenta e gramas e dezesseis centigramas) de Maconha; 328,39g (trezentos e vinte e oito gramas e trinta e nove centigramas) de Cocaína; 159,05g (cento e cinquenta e nove gramas e cinco centigramas) de cocaína, e 12,74g (doze gramas e setenta e quatro centigramas) de Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental.

Ademais, em seu interrogatório, o réu mostrou-se lúcido.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem, ainda mais no caso, em que o próprio réu assumiu que a droga era de terceira pessoa e ele estava somente guardando-a, em troca de pagamento em

dinheiro.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 2.443,74 gramas de drogas), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), elevo a pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, elevo a pena em mais 1/3 (um terço) em virtude da agravante da multirreincidência (fls. 358 – processo nº 0001793-74.2016.8.26.0637; fls. 359 – processo nº 0003239-22.2015.8.26.0637; fls. 359/360 – processo nº 0003869-78.2015.8.26.0637; e fls. 360 – processo nº 0003871-48.2015.8.26.0637), resultando em 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. Ainda nesta fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em

1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, entre os requisitos legais para tal benefício, o acusado deve ser primário, condição que o réu não ostenta.

Ademais, ainda que o réu fosse primário, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que só vem confirmar a não incidência da causa de diminuição supracitada.

Torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR NAILSON DA PAZ SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 12/12/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível, porque a pena aplicada é superior a quatro anos e o réu é multirreincidente em crime doloso, não preenchendo, pois, os requisitos legais para a substituição. Afora isso, o réu guardava considerável quantidade de entorpecentes para entrega a consumo de terceiros, o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado.

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão preventiva foi decretada às fls. 109/110, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir.

Por fim, anote-se que o réu guardava grande quantidade de drogas, o que traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, lembrando que o acusado é reincidente em crime doloso.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado, estão as decisões proferidas nos Habeas Corpus impetrados em favor do acusado, que tiveram suas liminares indeferidas (fls. 203/206 e 274/276), e, ao final, sua ordem denegada e não conhecido, respectivamente (fls. 364/370 e 371/375).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada às fls. 268/272, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Restou provada a procedência ilícita do dinheiro apreendido (fl. 129 - R\$ 2.276,00), razão pela qual não há como se deixar de reconhecer que é produto do

tráfico de entorpecente praticado pelo acusado. Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido à fl. 129 e depositado nos autos.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supra determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos demais objetos apreendidos às fls. 37/39, diante da natureza dos objetos (e por ser instrumento para a prática do tráfico de drogas), entendo não ser caso de perda para o SENAD, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, mas que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado da presente.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 760,00) e sobre a destruição da balança de precisão, instruindo-se o ofício com as cópias acima mencionadas.

Em relação ao veículo apreendido fl. 37/39, Placa DCY7998 Chassi 9BWK05W89P132966, Tipo Caminhonete, Ano Fabricação 2009, Ano Modelo 2009, Marca VW/SAVEIRO 1.6, Combustível Álcool/Gasolina/GNV, Cor Prata, levando em conta que pertence a terceira pessoa, conforme documentos juntados no "apenso de restituição de veículo" nº 0001813-59.2022.8.26.0077, e que restou demonstrado que não estava sendo usado como instrumento do tráfico de drogas, determino que se proceda à restituição do veículo ao seu respectivo proprietário, expedindo-se o necessário, anotando que o veículo está na posse de um terceiro depositário (fls. 40).

Fica, pois, prejudicado o pedido de restituição do veículo formulado em apenso.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA